

CLOVIS GORCZEWSKI
(ORG.)

DIREITOS
HUMANOS E
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA

VOL. XI



ISBN 978.65.88604-29-8

1ª edição – 2020

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, sem autorização expressa do autor ou da editora. A violação importará nas providências judiciais previstas no artigo 102, da Lei nº 9.610/1998, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Conselho Editorial

Dr. Liton Pilau Sobrinho – UPF/UNIVALLI

Dra. Elenise Felzke Schonardie – UNIJUI

Dra. Denise Pires Fincato – PUCRS

Dr. Luis Carlos Amezua Amezua – UVA/ESPANHA

Dra. Salette Oro Boff – UNISC/IMED

Dra. Margarita Tarabini-Castellani Aznar – UIB/ESPANHA

Dr. Tirso Ester Sanchez – ULPGC/ESPANHA

Dra. Nuria Belloso Martin – UBU/ESPANHA

Dra. Luciana Turati – UNIVATES

Dr. Ricardo Hermany – UNISC

Dra. Arancha Moreton Toquero – UVA/ESPANHA

Editora-chefe

Karla Viviane Rech

Projeto gráfico e diagramação

Editora Imprensa Livre

(51) 3249-7146

Rua Comandá, 801

Cristal – Porto Alegre/RS

karla.editora@gmail.com

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

D598 Direitos humanos e participação política / Clovis
Gorczewski, organizador. – 1. ed. – Porto Alegre:
Imprensa Livre, 2020.

536 p. ; v. XI

ISBN 978.65.88604-29-8

1. Direito. 2. Direitos humanos. 3. Política. I.
Gorczewski, Clovis.

CDU 342.7

Bibliotecária responsável: Andréa Inês Calini – CRB 10/2029

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO, 8

Marcos Roberto de Lima Aguirre

DIFICULTADES PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD MATERIAL: UN ANÁLISIS DESDE UNA DOBLE VERTIENTE, 10

Nuria Belloso Martín

METODOLOGIAS ATIVAS: UMA NOVA ABORDAGEM DE ENSINO COM ÊNFASE NOS DIREITOS HUMANOS, 36

Marli Marlene Moraes da Costa

Rodrigo Cristiano Diehl

A INEFETIVIDADE DAS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E A NECESSIDADE DE EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS, 57

Clovis Gorczewski

Micheli Piuccio

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE AUSTERIDADE E DE OFENSIVA ANTIGÊNERO, 78

Suelem Silveira Cardoso

Simone Andrea Schwinn

A DESATUALIZAÇÃO DO PENSAMENTO DO FILÓSOFO ROMANO CÍCERO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LEIS E GUERRA: O ESPAÇO DOS DIREITOS HUMANOS NO FLAGELO DOS HOMENS, 102

Anatércia Rovani Pilati

Reisson Ronsoni dos Reis

**O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO CONTEXTO DO CONSTITUCIONALISMO
CONTEMPORÂNEO: UM DEBATE A PARTIR DAS
MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LINDB, 118**

José Sérgio da Silva Cristóvam

Thanderson Pereira de Sousa

**SUBSÍDIOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO
E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, 146**

André Viana Custódio

Matheus Denardi Paz Martins

**PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL:
A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO PELA VIA
CONSENSUAL, 167**

Fábio Roque Sbardellotto

**NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS E PLURALISMO JURÍDICO:
INTERCONEXÕES NO CONTEXTO JURÍDICO-SOCIAL, 188**

Adriane Medianeira Toaldo

**A IMPORTÂNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NA APURAÇÃO
E PUNIÇÃO DA VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A
MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO, 208**

Caroline Fockink Ritt

Eduardo Ritt

**A ESTEREOTIPAÇÃO FEMININA COMO MARCA DA
VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO MERCADO DE CONSUMO, 228**

Bárbara Michele Morais Kunde

**CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: CASO
DA FAZENDA BRASIL VERDE – UMA ANÁLISE DA DECISÃO, 248**

Gustavo Jaques

O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONTEXTO DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO: UM DEBATE A PARTIR DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LINDB

José Sérgio da Silva Cristóvam⁽¹⁾

Thanderson Pereira de Sousa⁽²⁾

Considerações iniciais

¹ Professor Adjunto de Direito Administrativo no Curso de Graduação em Direito e no Programa de Mestrado e Doutorado do PPGD/UFSC. Doutor em Direito Administrativo pela UFSC (2014), com estágio de Doutorado Sanduíche junto à Universidade de Lisboa – Portugal (2012). Mestre em Direito Constitucional pela UFSC (2005). Membro fundador e Presidente do Instituto Catarinense de Direito Público (ICDP). Membro fundador e Diretor Acadêmico do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina (IDASC). Conselheiro Federal da OAB/SC. Presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB Nacional. Presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB/SC. Membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB/SC. Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Público do CCJ/UFSC (GEDIP/CCJ/UFSC) e membro da Rede de Pesquisa em Direito Administrativo Social (REDAS). E-mail: jsclistovam@gmail.com - <http://orcid.org/0000-0001-8232-9122>.

² Doutorando em Direito Administrativo pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC) (2020). Bolsista CAPES/PROEX. Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (PPGD/UFC) (2019). Membro do Grupo de Estudos em Direito Público do CCJ/UFSC (GEDIP/CCJ/UFSC), do Grupo de Pesquisa em Serviços Públicos e Condições de Efetividade (PPGD/UFC) e da Rede de Pesquisa em Direito Administrativo Social (REDAS). E-mail: thandersonsousa@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0003-0725-3572>.

Historicamente, a noção de Estado moderno⁽³⁾ está intimamente atrelada ao debate em torno da separação de poderes e, nessa lógica, ao sistema de freios e contrapesos que tende a um ambiente propício ao controle, com vistas a coibir qualquer forma exacerbada ou indevida de concentração de poder – que sempre é terreno fértil para condutas mais ou menos absolutistas. O desenvolvimento do Estado moderno não negligenciou a importância das instâncias controladoras – fundamentais ao próprio funcionamento das instituições –, que foram se modificando e aperfeiçoando, em acordo com as respectivas condições políticas, econômicas e jurídicas de cada tempo e lugar.

Atualmente, cumpre reconhecermos que a Administração Pública⁽⁴⁾ está submetida a um conjunto de normas jurídicas (regras e princípios que compõe o regime jurídico-administrativo) assecutorário da defesa e persecução do interesse público,⁽⁵⁾ instituindo poderes-deveres para tal objetivo, o que a distingue de outros sujeitos de direito. Ocorre que a existência desse regime jurídico específico resulta, consequentemente, num sistema de controle.

³ A doutrina política, em geral, atribui o “moderno” emprego do termo “Estado” (*status*), na intenção de configurar sociedades políticas organizadas e permanentes, à obra “*O Príncipe*” de Nicolau Maquiavel, que representa um importante marco para a ciência política e para o estudo da teoria do Estado. Sobre o tema, ver: MAQUIAVEL, Nicolau. **O príncipe**. Tradução de Maria Júlia Goldwasser. 3. ed. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

⁴ Para evitar confusões semânticas, o uso da expressão escrita com letras minúsculas – administração pública – será reservado à atividade administrativa, restando à grafia com maiúsculas – Administração Pública – para aludir ao conjunto de entidades jurídicas que podem desenvolver a atividade administrativa. Nesse sentido, ver: RIVERO, Jean. **Direito administrativo**. Tradução Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina, 1981. p. 13.

⁵ Ultrapassam os limites desse estudo o debate mais aprofundado sobre o conceito de interesse público e sua centralidade para o regime jurídico-administrativo. Apenas em breves considerações, pode-se dizer que o “conceito de interesse público confunde-se com os valores indisponíveis assegurados pela Constituição, sob o signo inafastável dos direitos fundamentais e da centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana (personalização da ordem constitucional)”. Sobre a noção de interesse público, ver: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **Administração Pública democrática e supremacia do interesse público**: novo regime jurídico-administrativo e seus princípios constitucionais estruturantes. Curitiba: Juruá, 2015. p. 98-117.

Nesse contexto e a partir de tais questões, pretendemos analisar a relação de implicação entre o desenvolvimento do constitucionalismo brasileiro, pós-Constituição de 1988, e as instâncias de controle da Administração Pública no Brasil, de forma a discutir o atual estágio da função controladora, especialmente no que toca aos limites e possibilidades da sua implicação na promoção da eficiência estatal. Para tanto, nosso estudo parte das seguintes questões centrais: quais os parâmetros de entrelaçamento e implicação entre o constitucionalismo pós-Constituição de 1988 e a questão do controle da Administração Pública? A partir da Lei nº 13.655/2018, mais especialmente os seus arts. 20 a 23, quais os novos parâmetros para a atuação das instâncias controladoras e se isso pode impactar positivamente no sentido da promoção da eficiência no agir administrativo?

Do ponto de vista metodológico, empregamos abordagem dedutiva, avaliando o nosso constitucionalismo contemporâneo e as repercussões ocorridas no âmbito do controle administrativo, estabelecendo, ao final, um panorama da modelagem atual da ação controladora. O texto apresenta, de forma sequencial, duas seções abordando (i) a relação entre constitucionalismo brasileiro pós-Constituição de 1988 e o controle da Administração Pública; e, (ii) o redimensionamento da atividade de controle e seus elementos na qualidade de promotores do princípio da eficiência, com ênfase aos arts. 20 a 23 da Lei nº 13.655/2018.

Apenas para antecipar, cumpre ressaltarmos que a superação da chamada doutrina constitucional da efetividade, pautada num modelo demasiado plástico de neoconstitucionalismo, em especial se visto pelas lentes de uma frouxa, casuística e até iletrada “teoria da ponderação à brasileira”, tenderia mesmo a abrir caminho para o redimensionamento dos modos de controle da atuação administrativa no paradigma do constitucionalismo contemporâneo, de forma a assegurar o retorno do pêndulo para padrões minimamente racionais de deferência às escolhas do gestor público e o contexto peculiar de suas decisões. Muito na esteira da Lei nº 13.655/2018, com o potencial de

delinear novos parâmetros para o controle da Administração Pública, com condição para maximizar os efeitos da eficiência administrativa.

O controle da Administração Pública no contexto do constitucionalismo pós-Constituição de 1988: do agora vai ao salve-se quem puder!

O paradigma do constitucionalismo dirigente influenciou, efetivamente, a teoria constitucional brasileira, sobretudo nos debates constituintes de 1987/1988 e pós-Constituição de 1988. Por esse modelo, nossa Constituição estabelece uma extensa pauta de programas, metas e fins a serem alcançados pelo Estado e na sua relação com a Sociedade. As disposições constitucionais instituem uma espécie de agenda a ser perseguida pelos poderes do Estado, máxime pelo Executivo. Para uma breve síntese, a lógica dirigente possui duas dimensões: (i) garantística, pois o Estado deve assegurar as garantias individuais; e, (ii) prestacional, havendo a necessidade de atuação direta na promoção de direitos sociais.

Para José Joaquim Gomes Canotilho, uma Constituição dirigente⁽⁶⁾ possui diversas normas-tarefas e fins, definidoras de ações e rumos do Estado. Desse modo, as Constituições do tipo não se prestam apenas para a individualização de órgãos estatais e repartição de competências, mas, sim, buscam, inequivocamente, comandar a ação do Estado, com metas estabelecidas, materializando o papel transformador da ação pública.⁽⁷⁾ Importante destacar que, para o autor, a concretude das Constituições dirigentes depende, diretamente, da

⁶ Exemplo contudente de Constituição dirigente é a Constituição Portuguesa de 1976, que estrutura diversos objetivos no sentido de configurar uma sociedade livre, justa e solidária, conforme o art. 1º, bem como busca estabelecer a democracia nas perspectivas social, econômica e cultural (art. 2º). Sobre o tema, ver: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Constituição dirigente e vinculação do legislador**: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.

⁷ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 217.

participação democrática, qualificando e estimulando o desenvolvimento dos programas firmados no texto constitucional.

A Constituição de 1988, síntese de um grande acordo sociopolítico, multicolorida pela vivificadora e extensa aquarela de direitos sociais, numa agenda de promessas emancipatórias, libertárias e de igualdade social, indicava que deixaríamos para trás o longo período de ditadura militar, em meio àquela ideia geral do “agora vai”!

Por outro lado, a década de 1990 e, sobretudo, o início dos anos 2000, acabou por revelar alguns efeitos colaterais desse nosso modelo de Constituição dirigente, dentre os quais a expressiva margem de atuação (não contingencial/excepcional) das instâncias de controle na conformação do que entendiam ser a vontade constitucional, em especial o Poder Judiciário. Numa visão positiva desse processo, Cláudio de Souza Pereira Neto e Daniel Sarmento sustentam que houve a associação da teoria dirigente com “institutos dogmáticos e processuais tendentes à efetivação judicial da Constituição”.⁽⁸⁾ Na mesma linha, outra explicação para atuação mais frequente do Judiciário seria o baixo índice de ordenação e participação da sociedade civil.⁽⁹⁾

Com efeito, o constitucionalismo brasileiro passou a lidar com a chamada “doutrina da efetividade”, apontada por alguns como “influência decisiva para a compreensão e aplicação da Constituição Federal de 1988”,⁽¹⁰⁾ a ensejar explicitamente a atuação direta do Judiciário na consolidação de sua força normativa. Luís Roberto Barroso, um dos principais expoentes dessa concepção, concebe uma espécie de Constituição viva, significativa, associando remédios e normas constitucionais, de jeito a tutelar judicialmente direitos individuais e coletivos.⁽¹¹⁾

⁸ SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. **Direito constitucional**: teoria, história e métodos de trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 196.

⁹ KRELL, Andréas Joachim. Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). **A Constituição concretizada**: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 46.

¹⁰ SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. **Direito constitucional**: teoria, história e métodos de trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 197.

¹¹ BARROSO, Luís Roberto. **O direito constitucional e a efetividade de suas normas**: limites e possibilidades da Constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

Uma posição que está longe de ser uníssona e, muito menos, infensa a críticas. Neste sentido, Gilberto Bercovici pondera que a Constituição de 1988 inaugurou um renovado projeto de nação e transformações por meio de políticas públicas, revigorando as bases do Estado, porém, não houve materialidade desse “ideal”, com graves problemas para o constitucionalismo brasileiro. Dessarte, a tal “autointitulada ‘doutrina brasileira da efetividade’ e a redução do debate constitucional às questões envolvendo a dicotomia entre regras e princípios ou às questões hermenêuticas e de interpretação”⁽¹²⁾ findou por deslocar a discussão, sobretudo, para o Judiciário, esquecendo-se de que o cumprimento das disposições constitucionais e a alteração do *status quo* do Estado envolve também e primordialmente os Poderes Executivo e Legislativo.

As variáveis teórico-políticas do chamado pós-positivismo, com maior ou menor aproximação (não contingencial e sim constitutiva/estrutural) entre Direito e Moral, já havia lançado bases para a aplicação interpretativa/criativa do Direito a partir de princípios jurídicos abertos, de forma a averiguar a compatibilidade entre a ordem jurídica e normas morais. Inclusive, essa movimentação filosófica, em geral, oposta à teoria kelseniana, vinha geralmente justificada como impeditivo de que o Direito pudesse ser empregado para políticas repressivas e excludentes, a exemplo da Alemanha nazista.⁽¹³⁾ Uma ideia largamente difundida, mas de duvidosa densidade histórica, teórica e filosófica, até porque não há maiores evidências capazes de sustentar que as atrocidades do período nazista possam ser colocadas na conta do positivismo kelseniano.⁽¹⁴⁾

¹² BERCOVICI, Gilberto. Estado intervencionista e Constituição social no Brasil: o barulho ensurdecedor de um diálogo entre ausentes. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Coords.). **Vinte anos da Constituição Federal de 1988**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 734.

¹³ Nas sombras da Constituição de Weimar, o partido nazista ascendeu ao poder e instituiu um regime autoritário e “criminoso”. Sobre o tema, ver: ARENDT, Hannah. **Origens do totalitarismo**: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 2013.

¹⁴ Sobre o tema, ver: DIMOULIS, Dimitri. **Positivismo Jurídico**: Introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006.

Com efeito, a lógica pós-positivista de ataque às alegadas incoerências do positivismo conduziu ao desenvolvimento de algumas teses mais ou menos agrupadas em torno da noção de neoconstitucionalismo,⁽¹⁵⁾ com o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais, os métodos abertos de interpretação jurídica, a constitucionalização do Direito, a eficácia direta de direitos prestacionais e a judicialização. No palco do neoconstitucionalismo, o Poder Judiciário passa a ser o ator principal, num protagonismo que completa em si expressiva atuação política para, então, passar a concretizar normas constitucionais e mesmo dizer o que é ou não a vontade constitucional e, até em arroubos usurpadores mais extremados, dizer que o que a Constituição disse não era bem isso, pois não alinhado à vontade das ruas.

Neste cenário, a clássica noção de separação dos poderes é superada para admitir, então, a clara flexibilização de competências em favor de um protagonismo jurídico, ou melhor, judicial,⁽¹⁶⁾ a pretexto de salvaguarda à Constituição. Disso se retira que o “neoconstitucionalismo tem um foco muito centrado no Poder Judiciário, no qual deposita enormes expectativas no sentido de concretização dos ideais emancipatórios presentes nas constituições contemporâneas”⁽¹⁷⁾ e, assim, procura a elaboração de parâmetros para orientar a atuação dos juízes.

Aqui, Lenio Luiz Streck elabora sólidas críticas ao neoconstitucionalismo, em especial ao que considera seu elemento central, no caso a ponderação, que necessariamente implicará em discricionariedade. Uma abertura que conduz ao ativismo judicial, uma vez que a ponde-

¹⁵ Para uma análise do chamado “neoconstitucionalismo” como equivalente ao “pós-positivismo”, ver: ATIENZA, Manuel. Entrevista a Robert Alexy. **Cuadernos de Filosofía del Derecho**, Alicante, n. 24, p. 671-687, 2001, p. 672-673. Em sentido semelhante, ver: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos. **Hermenêutica e argumentação neoconstitucional**. São Paulo: Atlas, 2009. p. 25-44.

¹⁶ BARAK, Aharon. **The judge in a democracy**. Princeton: Princeton University Press, 2006.

¹⁷ SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Controle de constitucionalidade e democracia: algumas teorias e parâmetros de ativismo. In: SARMENTO, Daniel (Coord.). **Jurisdição constitucional e política**. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 99.

ração tende a levar ao irracional sopesamento: o intérprete define os princípios a serem sopesados. Sobre o tema, o autor vaticina: “afastei-me do neoconstitucionalismo, porque ele aposta em elementos não democráticos, como a ponderação e a discricionariedade judicial”⁽¹⁸⁾.

Nesse quadrante, Streck sustenta ser imperativo abandonar o neoconstitucionalismo na condição de paradigma constitucional, de forma a entendermos o constitucionalismo contemporâneo, que resultou nas Constituições do segundo pós-guerra, como a prática político-jurídica democrática, fundada na Constituição normativa e na integridade da jurisdição. Isso implicaria, portanto, na utilização dos princípios jurídicos como balizadores da discricionariedade, sobremodo a judicial, mas não como “carta branca” aos juízes, e sim como limites à interpretação e aplicação do Direito.⁽¹⁹⁾

Todas essas questões acabaram por desaguar diretamente numa expressiva ampliação dos espaços de controle da atividade administrativa em geral, inclusive aquelas de feição essencialmente política. A gestão pública brasileira passou a sofrer o crivo, cada vez mais abrangente e quase totalizante, das mais diversas instâncias e sistemas de controle externo (Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas etc.), muitas das vezes a partir de pautas político-morais vestidas com roupas jurídicas, por serem informadas pelas bitolas abertas e irracionalmente aplicadas da ponderação de princípios à brasileira.⁽²⁰⁾ Situações que, em casos mais extremados, acabaram por conduzir mesmo ao estrangulamento da Administração Pública como instância de decisão e gestão política dos interesses da coletividade. Do festejado sentimento do “agora vai” pós-Constituição de 1988, o

¹⁸ STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o constitucionalismo contemporâneo. **Revista do CEJUR TJSC**, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 27-41, out. 2014. p. 37. Disponível em: <https://cejur.emnuvens.com.br/cejur/article/viewFile/64/49>. Acesso em: 16 mai. 2020.

¹⁹ STRECK, Lenio Luiz. **Verdade e consenso**: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

²⁰ Sobre o tema, ver: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Menos princípios, mais regras: a teoria da ponderação na encruzilhada do decisionismo. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, ano 5, n. 03, p. 993-1023, 2019. Disponível em: http://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/3/2019_03_0993_1023.pdf. Acesso em: 16 mai. 2020.

irrefletido alargamento do ambiente de insegurança jurídico-política acabou por nos conduzir a uma espécie de “salve-se quem puder”, a redundar num cenário de “apagação das canetas” e de “Administração Pública do medo”.⁽²¹⁾

Aqui se interligam os debates em torno do constitucionalismo brasileiro contemporâneo no contexto do controle da Administração Pública. Para os contornos do presente estudo, entendemos que o controle da Administração Pública abarca todas as funcionalidades fiscalizatórias e corretivas *lato sensu*, imputadas aos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, bem como as demais instâncias controladoras estatais e a Sociedade em geral, com vistas à garantia do cumprimento das regras e princípios inerentes ao regime jurídico-administrativo.

Conforme amplamente difundido, o chamado controle administrativo pode tanto ser interno (realizados pelos sistemas de controle do próprio órgão ou ente público controlado) como externo, realizado por órgão controlador situado fora da estrutura controlada, a exemplo do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público etc.

Sobre o controle interno, trata-se de elemento endógeno da Administração, que mira o cumprimento das disposições normativas (controle de legalidade) e harmonização de juízos de conveniência e oportunidade das ações administrativas no apossamento do interesse público (controle de mérito). No entanto, em que pese os diversos instrumentos conducentes ao controle interno,⁽²²⁾ ainda há considerável aviltamento dessa função. No caso, já em 1990, Odete Medauar apontava essa situação de desvalorização e reforçava a capacidade que

²¹ NIEBUHR, Joel de Menezes; NIEBUHR, Pedro de Menezes. Administração Pública do Medo: ninguém quer criar, pensar noutras soluções. O novo pode dar errado e o erro é punido severamente. **JOTA**, São Paulo, nov. 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/administracao-publica-do-medo-09112017>. Acesso em: 16 mai. 2020.

²² Sobre o tema, ver: MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo moderno**. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

os mecanismos internos de controle têm para aperfeiçoar a atividade administrativa.⁽²³⁾

Inclusive, não parece difícil admitir que, na esteira do constitucionalismo de efetividade no Brasil, que evoluiu para as teses do neoconstitucionalismo e transferiu consideravelmente a concretização das promessas constitucionais para a instância judicial, o controle interno não despontou como grande indutor ao bom exercício da atividade administrativa.

Com efeito, a alargada associação do avanço na concretização de promessas constitucionais pela via judicial e de outras instâncias pode ter concorrido para que, de certo modo, a atuação da Administração Pública e mesmo do Parlamento fosse mesmo subestimada em suas potencialidades, inclusive de forma a aprofundar certo desapego às instâncias democráticas.⁽²⁴⁾

Situação ainda mais complexa e especialmente traumática para a gestão pública está exatamente na sensível restrição às instâncias e âmbitos de legítima e democrática iniciativa política dos gestores públicos, particularmente em casos de nítido controle positivo do mérito administrativo, de forma a suplantar a discricionariedade administrativa, direta ou indiretamente, pela discricionariedade das demais instâncias de controle externo, em especial pela via de uma ponderação de princípios que floresce frondosa no terreno fértil do “vale-tudo hermenêutico ao gosto do freguês” e no “reino do tudo depende”.⁽²⁵⁾

²³ MEDAUAR, Odete. Controles internos da administração pública. **Revista da Faculdade de Direito – Universidade de São Paulo**, v. 84, n. 84-85, p. 39-55, jan. 1990. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67131/69741>. Acesso em: 16 mai. 2020.

²⁴ A crise da democracia na contemporaneidade não é “luxo” tupiniquim e nem é fenômeno que permita análises superficiais ou simplistas; é tema complexo, multifacetado e que parece indicar certa tendência em diferentes países, e que ultrapassa os contornos do presente estudo. Sobre o tema, ver: LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018; RANCIÈRE, Jacques. **O ódio à democracia**. São Paulo: Boitempo, 2014.

²⁵ Sobre o tema, ver: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Menos princípios, mais regras: a teoria da ponderação na encruzilhada do decisionismo. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, ano 5, n. 03, p. 993-1023, 2019. Disponível em: http://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/3/2019_03_0993_1023.pdf. Acesso em: 16 mai. 2020.

A busca pela efetividade constitucional, com o reconhecimento da normatividade dos princípios e a ampla constitucionalização do Direito, inclusive com a adequada superação dos direitos sociais como meras pautas programáticas, tudo isso também contribuiu para a expansão do controle externo da Administração Pública e redução das tradicionais esferas de discricionariedade administrativa. Inclusive, sobre a questão da discricionariedade administrativa, interessante recuperar as considerações de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quando assinala que “consequência dessa redução da discricionariedade administrativa foi a ampliação do controle externo sobre os atos da Administração Pública. Especialmente o Poder Judiciário passou a examinar aspectos que antes eram vistos como integrantes do mérito”.⁽²⁶⁾

Isso não equivale a negar que haja, sim, efeitos positivos no constitucionalismo brasileiro pós-Constituição de 1988. O que queremos é chamar a atenção para o fato de que a doutrina da efetividade e o neoconstitucionalismo, especialmente na questão da ponderação à brasileira, também contribuíram para sensíveis externalidades negativas, com a hipertrofia das instâncias de controle externo e seu avanço sobre a faixa política da discricionariedade administrativa, de forma a substituir escolhas políticas do gestor pelas do controlador, pela via de voluntaristas condutas interpretativas, fiscalizatórias e corretivas.

Apenas para exemplificar, cumpre recuperarmos a questão do controle judicial de políticas públicas, em matéria de direitos sociais, como na área da saúde. Uma espécie de voluntarismo de concretização da Constituição até inicialmente festejado, mas que veio a se ampliar em tal magnitude que passou a prejudicar as políticas universalistas de acesso à saúde e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS).⁽²⁷⁾

²⁶ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites do controle externo da Administração Pública: ainda é possível falar em discricionariedade administrativa? **Revista Brasileira de Direito Público – RBDP**, Belo Horizonte, ano 11, n. 42, p. 1-12, jul./set. 2013. p. 9-10. Disponível em: <https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Limites-do-controle-externo.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2020.

²⁷ Sobre o tema, ver: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; CIPRIANI, Manoella Peixer. Sobre o ativismo judicial nas questões relacionadas ao direito à saúde: mensageiro da boa nova ou lobo em pele de cordeiro. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v.

Fornecimento de medicamentos, muitos ainda não padronizados; tratamentos específicos, alguns até experimentais, etc., inclusive num certo paternalismo que não encontra amparo na Constituição de 1988.⁽²⁸⁾

Na mesma linha, serve de exemplo a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, numa aparente importação equivocada do instituto do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela modificação na dinâmica da política penitenciária brasileira, até mesmo na questão orçamentária, o que “contribuiu, em verdade, para o fortalecimento do ativismo judicial hermético e dissociado da realidade, interferindo, inclusive, na discricionariedade do gestor público”.⁽²⁹⁾

No entanto, essa espécie de controle de jaez voluntarista não fica restrito apenas à esfera judicial, espalhando seus efeitos também a outras instâncias, a exemplo dos Tribunais de Contas. Inicialmente, cumpre destacar positivamente os avanços institucionais, a independência e as funções próprias do Tribunal de Contas da União (TCU), para o desempenho da função controladora, na esteira dos arts. 71, 72 e 73 da Constituição de 1988, com indeléveis impactos à gestão pública como um todo. Os Tribunais de Contas têm autonomia estrutural e funcional, a ponto de Marçal Justen Filho apontar que “tudo o que caracteriza a existência de um ‘poder’ está presente na disciplina constitucional [...] do Tribunal de Contas. Só não tem a denominação formal de Poder”.⁽³⁰⁾

13, n. 3, p. 163-188, set./dez. 2017. Disponível em: <https://seer.imes.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1944/1403>. Acesso em: 16 mai. 2020.

²⁸ SOUSA, Thanderson Pereira de; TRAVASSOS, Mayara Andrade Santos. Saúde, judicialização e paternalismo no estado social em crise. **Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife**, Recife, v. 89, n. 2, p. 184-208, jan. 2018. p. 199. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA/article/view/110264/27782>. Acesso em: 16 mai. 2020.

²⁹ MAIA, Isabelly; SOUSA, Thanderson Pereira de. A inadequabilidade do estado de coisas inconstitucional para efetivação de direitos sociais no Brasil: por uma implementação dialógica, democrática e não ativista. In: SOUSA, Thanderson Pereira de (Org.). **Direitos fundamentais em debate**. Curitiba: Editora CRV, 2019. p. 21.

³⁰ JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 120.

Por outro lado, toda essa atmosfera de avanços a partir da ideia de força normativa da Constituição e, mais especialmente, a atuação principiológica turbinaram sobremaneira as já robustas funções dos Tribunais de Contas no Brasil, expandindo as possibilidades de fiscalização e correção, infelizmente numa cultura ainda muito mais de punição *a posteriori* do que de orientação preventiva. Na mesma direção, inclusive, há quem sustente que a fixação expressa do princípio da eficiência na Constituição, com a Emenda nº 19/1998, e na Lei nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo Federal) favoreceram essa expansão “[...] no controle administrativo externo, como o realizado pelo Tribunal de Contas”.⁽³¹⁾

Uma conjuntura que favorece ao voluntarismo como externalidade negativa. Sobre o tema, Francisco Maia Alves, analisando um conjunto de decisões do TCU (Decisão nº 215/1999-TCU-Plenário; Acórdão nº 1.755/2004-TCU-Plenário; Acórdão nº 749/2010-TCU-Plenário; Acórdão nº 1.977/2013-TCU-Plenário; Acórdão nº 1.823/2013-TCU-Plenário; Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário; Acórdão nº 255/2015-TCU-Plenário) sustenta a prática de verdadeiro ativismo controlador, com a amplificação das funções institucionais e a elaboração de regras e exceções para os casos julgados.⁽³²⁾

Estes são alguns dos contornos nos quais se insere a Lei nº 13.655/2018, que veio a incluir os arts. 20 a 30 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a designar condições para a atividade hermenêutica no Direito Público, com vistas a incentivar a segurança jurídica a partir de limites à atividade controladora em geral. Uma legislação que busca a reconfiguração dos sistemas de controle da

³¹ CABRAL, Flávio Garcia. O princípio da eficiência administrativa na jurisprudência do TCU. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 277, n. 1, p. 151-174, mai. 2018. p. 193. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/74805>. Acesso em: 16 mai. 2020.

³² ALVES, Francisco Sérgio Maia. O ativismo na atuação jurídico-administrativa do Tribunal de Contas da União: estudo de casos. **Revista de Informações Legislativas**, Brasília, a. 53, n. 209, p. 303-328, jan./mar. 2016. p. 323-324. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/520010/001063276.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso: 16 mai. 2020.

Administração Pública, de maneira a coibir e mesmo afastar eventuais excessos e externalidades prejudiciais à gestão pública – numa espécie de “novo agora vai”!

Sobre a Lei nº 13.655/2018 e os novos parâmetros para o controle estatal: será que podemos renovar a pauta da eficiência administrativa?

A Lei nº 13.655/2018, ao estabelecer critérios de interpretação e limites à atuação das instâncias controladoras no contexto do Direito Público almeja, decerto, fixar parâmetros mínimos à decisão em sede de controle da Administração Pública. Ademais, todos os Poderes e órgãos estatais submetem-se às definições da LINDB, conforme se extrai do seu art. 20, interpretação que é fortalecida pelo Enunciado nº 1 do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA): “as expressões ‘esfera administrativa, controladora e judicial’ contidas na LINDB abrangem o exercício de todas as funções estatais que envolvam aplicação do ordenamento jurídico”.⁽³³⁾

Todavia, sem embargos, há repercussão específica no exercício da função controladora, tendo em vista certa recuperação do *locus* ordinário e mesmo uma espécie de proteção da discricionariedade. Assim, por mais que se considere a redução da discricionariedade administrativa, especialmente a partir de uma espécie de controle pautado na lógica da juridicidade, a mesma ainda remanesce e está alicerçada na própria dimensão da legalidade administrativa, que lhe serve de instância de legitimação e também marco limitativo.

Com efeito, as modificações trazidas pela LINDB tendem a dificultar que o controlador, no exercício de suas funções fiscalizatórias e corretivas, constitucionalmente previstas, utilize conceitos

³³ INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. **Enunciados relativos à interpretação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB e seus impactos no Direito Administrativo (2019)**. Disponível em: <http://ibda.com.br/noticia/seminario-promovido-pelo-ibda-aprova-enunciados-sobre-a-lindb>. Acesso em: 16 mai. 2020.

indeterminados para substituir a discricionariedade administrativa por seus juízos próprios. Até porque, se presente certa margem de segurança quanto à conjugação da discricionariedade administrativa dentro dos contornos do ordenamento jurídico, não faz sentido que qualquer instância controladora imponha suas próprias escolhas a partir de interpretações não responsivas. Há que se recuperar, sim, certa dimensão ampliada de deferência controladora às escolhas administrativas, salvo se contrárias à ordem jurídica.⁽³⁴⁾

A permanecer ampliada porosidade às interpretações voluntaristas das instâncias controladoras, haveria equivocada transgressão à separação de poderes, de forma a submeter a gestão pública aos contingenciais humores, sabores e dissabores das instâncias controladoras que, por mais bem intencionadas que sejam, não estariam legitimadas para tal atuação usurpadora. No entanto, com isso, não estamos a dizer que, em regra, há atuação controladora de forma ilegítima e voluntarista. Pelo contrário, estamos a dizer que os eventuais excessos, que estavam, sim, cada vez mais recorrentes, agora tende a um maior desencorajamento, porquanto expressa e normativamente contraindicados. Em poucas palavras, imperioso que se tome em conta a posição do gestor público e suas dificuldades.

Com a LINDB, o controle da Administração Pública passa a contar com alguns elementos redimensionadores, a saber: (i) consequencialismo; (ii) realismo; e, (iii) temporalidade.⁽³⁵⁾ Dimensões que,

³⁴ Comum e mesmo recorrente, no que toca à questão da deferência judicial, é recuperarmos o conhecido Caso *Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, julgado pela Suprema Corte estadunidense em 1984 e discutido até os dias atuais, quando afirmou, basicamente, que nas hipóteses nas quais o legislador não tenha disposto especificamente sobre determinado tema, ou ao menos em cláusulas legais para verificação de ambiguidades, a postura judicial a ser adotada deve seguir a perspectiva de deferência para com a escolha pública. Sobre o tema, ver: SUNSTEIN, Cass. *Chevron step zero*. **Virginia Law Review**, Virginia, v. 92, n. 2, 2006; SUNSTEIN, Cass. *Law and administration after Chevron*. **Columbia Law Review**, New York, v. 90, 1990.

³⁵ Cumpre ressaltar que os elementos estão para todo processo de interpretação e aplicação das normas de Direito Público. Entretanto, para fins de recorte do presente estudo, enfocamos os seus efeitos sobre o controle da Administração Pública, apontando – seguidamente – as potencialidades no âmbito da proteção das

sem margens para dúvida, indicam a institucionalização de um novo arquétipo para a função controladora, na esteira de um constitucionalismo também preocupado com a integridade das normas constitucionais, no sentido da ação administrativa e dos gestores públicos.

Ao discutir sobre o consequencialismo, Neil MacCormick afasta percepções extremas para compreender que razões e consequências são indispensáveis para a justificativa da decisão jurídica, não se tratando de opções morais ou políticas, mas de resultados e possibilidades que estão diretamente ligados à coerência do ordenamento jurídico,⁽³⁶⁾ em sua essência capaz de impor para o controlador o dever de “melhor deliberação”, promovendo o amadurecimento democrático das escolhas administrativas e função controladora.

Nesta esteira, o consequencialismo contempla, em seu conteúdo, três variáveis, aplicáveis a depender do caso de controle: prática, jurídica e administrativa. No consequencialismo prático (1) (art. 20), as decisões de controle que se fundarem em valores jurídicos abstratos deverão determinar o resultado prático da decisão, sua reverberação no mundo dos fatos, visando a evitar deliberações que, se no aspecto legal podem estar corretas, na práxis não produz efeitos ou estes são negativos. Ainda, há o dever de motivação (art. 20, parágrafo único), abarcando necessidade e adequação, cumulada com a previsão de alternativas previsíveis, para, de pronto, indicar que a decisão controladora é a mais satisfatória, mais eficiente para o interesse público, superando suas possíveis fragilidades.

As perspectivas jurídica (2) e administrativa (3) do consequencialismo (art. 21) estão intrinsecamente ligadas, mas é possível reparar sutil distinção entre ambas. Quando da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, o órgão controlador denotará o regime

escolhas administrativas e do interesse público, a evitar o “apagão das canetas” e a perpetuação de uma Administração Pública do medo, ocasionada pelo excesso de controle. Sobre o tema, ver: MOTTA, Fabrício; NOHARA, Irene. **LINDB no direito público**: Lei 13.655/2018. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

³⁶ MACCORMICK, Neil. **Rhetoric and the rule of law**: a theory of legal reasoning. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 101-102.

normativo aplicável aos possíveis efeitos já produzidos, mas que são desamparados pelo resultado retroativo (*ex tunc*) daquela decisão, tendo em consideração a situação concreta e a “segurança e certeza das relações jurídicas, boa-fé de terceiros, ausência de dolo do interessado”⁽³⁷⁾ (consequência jurídica). Igualmente, cumpre indicar expressamente como a decisão invalidadora impacta na atuação de promoção do interesse público (consequência administrativa).

Os prismas jurídico e administrativo, apesar de diferentes, caminham juntos para que, nos casos de invalidação, sejam equilibrados e avaliados os efeitos reais e, desse modo, a decisão seja a mais acertada possível, de forma a proteger/promover o interesse público. Sobre o tema, Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Vêras de Freitas asseveram que os arts. 20 e 21 criam viés realista para o processo deliberativo, pois “a decisão alheia à realidade não produz mais um ato jurídico lícito, nem, muito menos, justo”⁽³⁸⁾ e, também, efetivo.

No que toca ao realismo (art. 22), o mesmo impele os órgãos de controle, sobretudo externo, a firmemente considerar toda a sistemática que envolve as normas da gestão pública, os obstáculos e dificuldades do gestor, bem como as características de cada política pública. Portanto, não cabem julgamentos que ocorram num plano abstrato, considerando questões isoladas, pontuais. Nesse sentido, a ideia de realismo institui a necessidade de decisões com estruturação a partir da macro institucionalidade da Administração Pública, demandando conhecimento do planejamento administrativo e de questões restritivas (limites) referentes às políticas públicas. Em síntese, o realismo pode aperfeiçoar a atuação administrativa pelo exercício responsivo da função de controle, até porque, como adverte Vanice Regina Lirio do Valle, “o resultado desejável, sempre e sempre, da ação de controle

³⁷ MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo moderno**. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 154.

³⁸ MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Vêras de. **Comentários à Lei nº 13.655/2018: lei da segurança para a inovação pública**. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 51.

é reconduzir aquele que é destinatário inicial do cometimento constitucional ao desenvolvimento regular de suas atribuições”.⁽³⁹⁾

Por último, a temporalidade constitui gênero relativo à observância dos parâmetros interpretativos (orientações administrativas) vigentes no momento do fazimento do ato administrativo objeto do controle, englobando duas espécies: progressiva e regressiva. A temporalidade progressiva (art. 23) expõe que, na função de controle, existindo orientações gerais inéditas em referência a conteúdo indeterminado, faz-se imperiosa a fixação de regime de transição para sua implementação. Noutra ponta, a temporalidade regressiva (art. 24) impede que ato, contrato, ajuste, processo ou norma que já tenha produzido efeitos seja declarado inválido à sombra de novas orientações interpretativas, obrigando órgão controlador a retroagir temporalmente para exercer sua função na luz das orientações da época de corporificação do objeto de análise.

Com efeito, ao implementar novo e mais adequado paradigma de controle, a LINDB busca reforçar o respeito e deferência à instância administrativa, apoiando-se no consequencialismo, realismo e temporalidade na condição de institutos voltados à calibragem da atividade hermenêutica no Direito Público brasileiro. Por conseguinte, acaba por tender potencialmente à promoção da eficiência administrativa.

Em verdade, a manipulação de conceitos indeterminados associada ao (i) aumento das instâncias de controle e (ii) à paradoxal burocracia no exercício do papel corretivo conduziu à restrição e mesmo erosão da atuação do gestor público, que se tornou (e também se colocou como!) refém da “última palavra” das instâncias controladoras. Entre decidir e correr o sério risco de ser depois punido ou não decidir e aguardar que a decisão venha das instâncias de controle, o gestor passou a assumir uma postura recorrentemente omissiva. Sobre o tema, Fernando Vernalha Guimarães acertadamente diagnosticou que “acuados, os gestores não mais atuam apenas na busca da melhor

³⁹ VALLE, Vanice Regina Lirio do. **Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial**. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 71.

solução ao interesse administrativo, mas também para se proteger”.⁽⁴⁰⁾ Na mesma linha, Onofre Alves Batista Júnior e Sarah Campos identificam que “a cultura administrativa reinante, nesse contexto, é a do medo, a do receio da punição. Não se tenta aperfeiçoar ou buscar a solução adequada”.⁽⁴¹⁾

Uma realidade totalmente prejudicial à gestão pública e ao atingimento da eficiência administrativa, mormente quando se observa no Brasil limitações de todas as ordens (orçamentária, estrutural, estratégica etc.) que obstaculizam o papel do gestor público. Até porque, falar em eficiência administrativa deveria significar, muitas vezes, reconhecer certa margem à atitude criativa e espontânea, com caráter experimental, a testar, confirmar ou reformular o uso de técnicas planejadas na dinâmica, complexa e instável promoção do interesse público. O agir administrativo não deve ficar amarrado à idealização da “melhor opção” vinda de quaisquer das instâncias de controle.

O princípio da eficiência, incluído expressamente no texto constitucional pela Emenda nº 19/1998, essencialmente orienta que a ação administrativa tem de ser revestida de celeridade e acerto, de sorte que os resultados sejam adequados para a plena satisfação das necessidades coletivas e proteção da dignidade dos cidadãos, numa pauta de eficiência enquanto busca de otimização dos resultados da ação administrativa para a ampliação e qualificação da prestação de serviços públicos e desempenho das atividades estatais, voltados ao cumprimento daqueles objetivos traçados pelo art. 3º da Constituição de 1988. Com acerto, Emerson Gabardo sustenta que a “eficiência imputa a exigência, portanto, de ser alcançada a solução que seja ótima ao

⁴⁰ GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O direito administrativo do medo: a crise da ineficiência pelo controle. **Revista de Direito do Estado**, Salvador, v. 71, 2016. p. 01. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-cri-se-da-ineficiencia-pelo-controle>. Acesso em: 16 mai. 2020.

⁴¹ BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; CAMPOS, Sarah. A Administração Pública consensual na modernidade líquida. **Revista Fórum Administrativo**, Belo Horizonte, ano 14, n. 155, p. 31-43, jan. 2014. p. 38.

atendimento da finalidade pública, seja no espaço de decisão vinculada expressamente à lei, seja no espaço de decisão discricionária”.⁽⁴²⁾

Ora, se o próprio princípio da eficiência, em sua normatividade, demanda do gestor público soluções de excelência para a concretização do interesse coletivo e, considerando as limitações de formação da norma jurídica, não se pode prever todas as soluções para um Estado que é um total devir, muito mais difícil e mesmo quase inviável o atingimento dessa dimensão de eficiência sob as amarras de um modelo de controle sancionatório do qual decorre uma atmosfera de medo e insegurança.

Nesse quadrante, as normas trazidas pela LINDB e de obrigatoria aplicação na condução do controle da Administração fazem avançar na garantia de padrões mínimos de segurança jurídica e necessária estabilidade das regras do jogo.⁽⁴³⁾ Com isso, o gestor público pode mesmo acabar incentivado a abandonar sua indevida omissão defensiva e inovar em condutas que, essencialmente, conformem a eficiência administrativa e tendam à concretização do interesse público. Nada obstante, o desimpedimento para práticas inovadoras e o estímulo ao protagonismo da Administração não podem conduzir à desobediência da legalidade, aqui entendida em sentido amplo. O retorno do pêndulo deve ocorrer para equilibrar as relações entre as instâncias de execução e controle da atividade administrativa, mas nunca para desarticular o controle e viabilizar excessos da Administração Pública e condutas indevidas dos seus gestores.

Fixadas as “regras do jogo” na relação entre a atividade administrativa e as instâncias controladoras, desponta viável a construção de um novo cenário de expectativas: do controlador se espera alteridade para com as escolhas administrativas – se válidas e regulares; e do

⁴² GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência. In: NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano *et al.* (Coord.). **Enciclopédia jurídica da PUC – Tomo II**. São Paulo: PUC, 2017. p. 13. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/principio-da-eficiencia,-o_58edc663b888b.pdf. Acesso em: 16 mai. 2020.

⁴³ MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Vêras de. **Comentários à Lei nº 13.655/2018: lei da segurança para a inovação pública**. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 165.

gestor se espera muito mais do que omissões defensivas, espera-se sim a efetiva e eficiente promoção do interesse público, com destacado nível de excelência.

Um cenário que, verdadeiramente, permite a construção de decisões democráticas amadurecidas em termos de gestão,⁽⁴⁴⁾ de forma que as pautas políticas da Constituição de 1988 não sejam relegadas ao infértil terreno de gestores temerosos ou descrentes do seu papel de transformação social e desenvolvimento nacional. Igualmente, que as instâncias de controle, fiscalização e correção da atividade administrativa possam avançar na superação de uma cultura de controle repressivo, corretivo, posterior e, no mais das vezes, ineficiente.

Considerações finais

No Brasil, o desenvolvimento constitucional tem momentos peculiares que, decerto, refletem na atuação da Administração Pública e, da mesma forma, repercutem na respectiva atividade controladora. Sem dúvida, conforme avança, o Constitucionalismo jurídico-político molda as instituições do Estado.

Sobre nosso constitucionalismo pós-Constituição de 1988, a teoria da Constituição dirigente influencia marcadamente a forma de compreender as normas constitucionais. Posteriormente, a chamada doutrina da efetividade ganha terreno, buscando dar concretude aos dispositivos constitucionais e fazer vivos seus valores, com ou sem interpolação legislativa.

Nas pegadas do pós-positivismo, o neoconstitucionalismo emerge e vai a campo, reconhecendo a força normativa da Constituição e dos direitos fundamentais, instrumentalizado por uma hermenêutica

⁴⁴ Nada obstante as potencialidades da LINDB para essa tarefa, há sim posicionamentos que não veem nas reconfigurações insertadas pela Lei nº 13.655/2018 a qualidade de ferramental para tanto, mas tão somente meio de alargamento da discricionariedade administrativa. Sobre o tema, ver: PINTO, Élica Graziane *et al.* **Política pública e controle: um diálogo interdisciplinar em face da Lei nº 13.655/2018**, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 139.

ponderacionista criativa que quase tudo submete ao sopesamento de princípios e, infelizmente, faz turbinar toda sorte de ativismos voluntaristas.

Por certo, avançamos sim na concretização de várias das promessas constitucionais. Mas também, como séria externalidade negativa, a doutrina da efetividade e o ponderacionismo à brasileira acabaram por contribuir firmemente no deslocamento do cumprimento da Constituição para fora dos seus ordinários âmbitos de ortodoxia da democracia constitucional. Instâncias como o Poder Judiciário (mas não só ele!) passaram a decidir sobre tudo, inclusive questões eminentemente políticas e até sobre as quais já existia expressa escolha constitucional. Tudo isso, mal pesado e mal medido, acabou por redundar no acanhamento dos instrumentos internos de controle da Administração Pública e, por outro lado, a hipertrofia das instâncias do controle externo, a colocar o próprio gestor público numa incômoda e temerosa posição, em diversas situações refém da percepção dos órgãos de controle sobre o modo ideal de cumprir a Constituição e as políticas públicas dela decorrentes.

A maleabilidade da interpretação de conceitos abertos e indeterminados, associada à cultura do medo e a burocracia dos procedimentos de controle, jogou o gestor para uma zona (até certo ponto confortável!) de omissão defensiva, que inibe o processo decisório inovador e eficiente, numa clara disfuncionalidade institucional no contexto do Estado democrático de direito: (i) nem os sistemas de controle foram pensados para, a todo tempo, discutir e decidir sobre políticas públicas em geral; e, (ii) nem os gestores são eleitos para, sobre questões de política, aguardar o norte decisório das instâncias de controle. É imperativo que, o mais rápido possível, cada um volte para o seu quadrado!

Nesse contexto, a LINDB passa a conformar um novo paradigma para o controle da Administração Pública, especialmente pela definição das “regras do jogo” para interpretação e aplicação do Direito Público pelas instâncias controladoras. Há função controladora são normativamente previstos os seguintes parâmetros de conformação:

(i) consequencialismo (prático, jurídico e administrativo); (ii) realismo; e, (iii) temporalidade (progressiva e regressiva); na qualidade de balizas ao exercício da fiscalização e correção da ação pública. Uma clara proposta normativa de redefinição da cultura de controle no Brasil, com a superação da difundida ideia de medo que levou a certa paralisia na gestão pública.

Uma proposição que tem, ao menos em potência, condições de fazer avançarmos para um paradigma de controle da Administração Pública adequado ao marco constitucional e, inclusive, capaz de tonificar as estruturas administrativas para a promoção do princípio da eficiência, com o incentivo ao experimentalismo e à busca de soluções de excelência na persecução do interesse público e guarda dos cidadãos. Por outro lado, isso jamais poderá significar o amesquinamento do papel das instâncias de controle, essenciais em um Estado democrático de direito e, muito menos, odiosos excessos da parte dos gestores públicos. Ajudar na constante busca por esse fino equilíbrio é também papel da doutrina administrativista!

Referências

ALVES, Francisco Sérgio Maia. O ativismo na atuação jurídico-administrativa do Tribunal de Contas da União: estudo de casos. *Revista de Informações Legislativas*, Brasília, a. 53, n. 209, p. 303-328 jan./mar. 2016. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/520010/001063276.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso: 16 mai. 2020.

ARENDT, Hannah. *Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo*. São Paulo: Cia das Letras, 2013.

ATIENZA, Manuel. Entrevista a Robert Alexy. *Cuadernos de Filosofía del Derecho*, Alicante, n. 24, p. 671-687, 2001.

BARAK, Aharon. *The judge in a democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira*. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; CAMPOS, Sarah. A Administração Pública consensual na modernidade líquida. *Revista Fórum Administrativo*, Belo Horizonte, ano 14, n. 155, p. 31-43, jan. 2014.

BERCOVICI, Gilberto. Estado intervencionista e Constituição social no Brasil: o barulho ensurdecedor de um diálogo entre ausentes. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Coords.). *Vinte anos da Constituição Federal de 1988*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CABRAL, Flávio Garcia. O princípio da eficiência administrativa na jurisprudência do TCU. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 277, n. 1, p. 151-174, mai. 2018. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/74805>. Acesso em: 16 mai. 2020.

CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos. *Hermenêutica e argumentação neoconstitucional*. São Paulo: Atlas, 2009.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas*. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. *Administração Pública democrática e supremacia do interesse público: novo regime jurídico-administrativo e seus princípios constitucionais estruturantes*. Curitiba: Juruá, 2015.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Menos princípios, mais regras: a teoria da ponderação na encruzilhada do decisionismo. *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, ano 5, n. 03, p. 993-1023, 2019. Disponível em: http://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/3/2019_03_0993_1023.pdf. Acesso em: 16 mai. 2020.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; CIPRIANI, Manoella Peixer. Sobre o ativismo judicial nas questões relacionadas ao direito à saúde: mensageiro da boa nova ou lobo em pele de cordeiro. *Revista Brasileira de Direito*, Passo Fundo, v. 13, n. 3, p. 163-188, set./dez. 2017. Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1944/1403>. Acesso em: 16 mai. 2020.

DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico: Introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites do controle externo da Administração Pública: ainda é possível falar em discricionariedade administrativa? *Revista Brasileira de Direito Público – RBDP*, Belo Horizonte, ano 11, n. 42, p. 1-12, jul./set. 2013. Disponível em: <https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Limites-do-controle-externo.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2020.

GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência. In: NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano et al. (Coord.). *Enciclopédia jurídica da PUC – Tomo II*. São Paulo: PUC, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/principio-da-eficiencia,-o_58edc663b888b.pdf. Acesso em: 16 mai. 2020.

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O direito administrativo do medo: a crise da ineficiência pelo controle. *Revista de Direito do Estado*, Salvador, v. 71, 2016, p. 01. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle>. Acesso em: 16 mai. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Enunciados relativos à interpretação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB e seus impactos no Direito Administrativo (2019). Disponível em: <http://>

ibda.com.br/noticia/seminario-promovido-pelo-ibda-aprova-enunciados-sobre-a-lindb. Acesso em: 16 mai. 2020.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

KRELL, Andréas Joachim. Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A constituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning. Oxford: Oxford University Press, 2005.

MAIA, Isabelly; SOUSA, Thanderson Pereira de. A inadequabilidade do estado de coisas inconstitucional para efetivação de direitos sociais no Brasil: por uma implementação dialógica, democrática e não ativista. In: SOUSA, Thanderson Pereira de (Org.). Direitos fundamentais em debate. Curitiba: Editora CRV, 2019. p. 21-40.

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução de Maria Júlia Goldwasser. 3. ed. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Vêras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018: lei da segurança para a inovação pública. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

MEDAUAR, Odete. Controles internos da administração pública. Revista da Faculdade de Direito – Universidade de São Paulo, v. 84, n. 84-85, p. 39-55, jan. 1990. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67131/69741>. Acesso em: 16 mai. 2020.

MOTTA, Fabrício; NOHARA, Irene. LINDB no direito público: Lei 13.655/2018. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

NIEBUHR, Joel de Menezes; NIEBUHR, Pedro de Menezes. Administração Pública do Medo: ninguém quer criar, pensar noutras soluções. O novo pode dar errado e o erro é punido severamente. JOTA, São Paulo, nov. 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/administracao-publica-do-medo-09112017>. Acesso em: 16 mai. 2020.

PINTO, Élida Graziane et al. Política pública e controle: um diálogo interdisciplinar em face da lei nº 13.655/2018, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.

RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina, 1981.

SOUSA, Thanderson Pereira de; TRAVASSOS, Mayara Andrade Santos. Saúde, judicialização e paternalismo no estado social em crise. Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, Recife, v. 89, n. 2, p. 184-208, jan. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA/article/view/110264/27782>. Acesso em: 16 mai. 2020.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Controle de constitucionalidade e democracia: algumas teorias e parâmetros de ativismo. In:

SARMENTO, Daniel (Coord.). *Jurisdição constitucional e política*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

STRECK, Lenio Luiz. *Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o constitucionalismo contemporâneo. *Revista do CEJUR TJSC, Florianópolis*, v. 1, n. 2, p. 27-41, out. 2014. Disponível em: <https://cejur.emnuvens.com.br/cejur/article/viewFile/64/49>. Acesso em: 16 mai. 2020.

SUNSTEIN, Cass. *Law and administration after Chevron*. *Columbia Law Review*, New York, v. 90, 1990.

SUNSTEIN, Cass. *Chevron step zero*. *Virginia Law Review*, Virginia, v. 92, n. 2, 2006.

VALLE, Vanice Regina Lírio do. *Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.